

ARAFIAH BINTI AMAN

LWN

SULAIMAN BIN ALIAS

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Pengerusi), YA Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Nai'm bin Mokhtar (Panel), YA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Panel), 14 Januari 2019]

Kes Semakan No. 10000-003-0113-2018

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: Muhammad Hafiz bin Ab Rashid dari Tetuan Hafiz Nuaim & Partners

Peguam Responden: Musa bin Awang dari Tetuan Musa Awang & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN MAHKAMAH

Permohonan

[1] Kes ini merupakan satu permohonan semakan yang dibuat Pemohon kepada Mahkamah Rayuan untuk mendapatkan suatu perintah seperti berikut :-

- i. Mahkamah Mahkamah Rayuan Syariah membatalkan arahan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada prosiding bertarikh 23 hb Julai 2018 yang telah memutuskan seperti berikut:-

- a) Mahkamah menetapkan prosiding pemilihan anak yang telah dijalankan pada 11hb Jun 2018 adalah muktamad bagi penentuan orang yang berhak menjadi hadinah.
- b) Mahkamah menetapkan perbicaraan kes hanya berkaitan tentang hak lawatan, bersama dan bermalam sahaja.
- ii. Mahkamah Rayuan Syariah memerintahkan bahawa kes tuntutan Mengubah Perintah Hadanah melalui Saman No. 10300-026-0270-2017 di Mahkamah Tinggi Syariah dibicarakan mengikut pliding yang telah difailkan bagi menentukan pihak yang layak untuk menjadi hadinah bagi anak-anak seperti berikut:-

BIL	NAMA	NO. MYKID
1.	Aqilah Qasharina binti Sulaiman	040811-10-0424
2.	Haris Fahmi bin Sulaiman	081222-10-1577
3.	Adam Arman bin Sulaiman	110111-10-1013

- iii. Mahkamah Rayuan Syariah memerintahkan bahawa prosiding pemilihan anak yang telah dijalankan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 11hb Jun 2018 adalah tidak muktamad bagi keseluruhan prosiding kes tuntutan mengubah Perintah Hadanah di dalam saman No : 10300-026-0274-2017.
- iv. Lain-lain perintah yang difikirkan adil dan suai manfaat oleh Mahkamah yang mulia ini.

Fakta Kes

[2] Perayu dan Responden merupakan bekas suami isteri. Pihak-pihak telah bernikah pada 2/9/2000 dan telah bercerai dengan pada 23/2/2016. Hasil perkahwinan tersebut, mereka telah dikurniakan 3 orang anak.

[3] Pada 20/6/2017, Responden melalui Peguam Syariannya telah memfailkan tuntutan mengubah perintah Hadanah melalui saman no : 10300-026-00274-2017 di Mahkamah Tinggi Syariah, Sahah Alam Selangor.

[4] Responden melalui Peguam Syariannya telah memfailkan pembelaan dan tuntutan balas pada 24/8/2017, Jawapan kepada pembelaan dan pembelaan tuntutan balas pada 10/10/2017 dan Jawapan Pembelaan Tuntutan Balas pada 22/11/2017.

[5] Pemohon tidak berpuashati dengan arahan yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara pada prosiding pada tarikh 23/7/2018 dan telah memfailkan semakan melalui kes semakan No : 10000-003-0113-2018 berdasarkan alasan-alasan sebagaimana berikut:-

- i) YA Hakim Bicara sepatutnya memerintahkan kes tersebut dibicarakan dengan menyeluruh terhadap semua isu yang dibangkitkan oleh pihak-pihak. Perkara ini bertentangan dengan hukum syarak dan undang-undang di bawah seksyen 72 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang mana perlu dibuktikan setiap dakwaan di dalam pliding terlebih dahulu dan tidak sepatutnya menerima

sepenuhnya pilihan yang dibuat oleh anak-anak tersebut demi kebajikan dan kemaslahatan anak-anak tersebut terpelihara.

- ii) Pemilihan anak-anak tersebut tidak mutlak dan tidak mengikat YA Hakim Bicara.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[6] Bagi maksud semakan ini, kami telah meneliti rekod-rekod/catatan prosiding kes yang telah dijalankan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dan Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

[7] Dalam kes ini, kami mendapati kes-kes yang berkaitan dengan permohonan semakan ini adalah kes Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Saman No: 10300-026-0274-2017.

[8] Kuasa Mahkamah Rayuan Syariah dalam sesuatu prosiding semakan kes diperuntukkan di dalam seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan:

“Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidangkuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan”

[9] Skop kepada semakan yang disebut di dalam seksyen tersebut adalah dua iaitu, pertama: “apa-apa perkara” dan keduanya “prosiding”. Perkataan prosiding jelas maksudnya, iaitu prosiding yang dijalankan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Tetapi frasa “apa-apa perkara” yang maksudnya memerlukan kami membuat tafsiran apakah ia termasuk juga keputusan/penghakiman/perintah Mahkamah Tinggi Syariah. Pada pendapat kami apabila peruntukkan itu menyebut boleh menyemak pada mana-mana peringkat ia memberi maksud kes yang selesai diputuskan juga boleh disemak. Dengan kata lain keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah boleh disemak. Tafsiran ini selaras dengan Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 yang menetapkan “*Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan*”.

[10] Walau bagaimanapun kami berpendapat bagi semakan keputusan/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah ia tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak Rekod Kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak. Dalam hal ini kami merujuk kepada satu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes ***Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah***, Kes Mal (Semakan) No.14000-003-0035-2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 07/03/2012 sebagaimana berikut:-

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

[11] Dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid* (kes semakan mal Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan no 14000-003-0033-2012), Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan menegaskan prosiding juga boleh disemak. Ini menjadikan perkara yang boleh disemak adalah:-

- i) Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii) Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-
 - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
 - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[12] Apabila Mahkamah Rayuan telah membuat semakan terhadap sesuatu kes, Mahkamah Rayuan mempunyai kuasa untuk memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan seperti yang diperuntukan seksyen 68 di atas. Peruntukan tersebut memberikan kuasa yang luas kepada Mahkamah Rayuan untuk mengeluarkan apa-apa arahan demi keadilan dan ianya pada pendapat kami termasuk kuasa-kuasa yang boleh dibuat pada peringkat rayuan.

[13] Berikutan daripada itu kami telah memanggil dan menyemak rekod prosiding Kes Mal No: 10300-026-0274-2017 yang dikendalikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Berdasarkan proses semakan yang telah dijalankan, kami dapati bahawa :-

- i) Pada 5/4/2018, Mahkamah telah menetapkan pada 11/6/2018 untuk diadakan sesi temuduga anak-anak tersebut. Pihak-pihak telah bersetuju dengan arahan YA Hakim Bicara untuk diadakan sesi temuduga tersebut.
- ii) Pada 23/7/2018 YA Hakim Bicara telah menetapkan tarikh untuk prosiding perbicaraan kes. Semasa prosiding tersebut YA Hakim Bicara telah memutuskan arahan sebagaimana berikut :-
 - a) Mahkamah menetapkan prosiding pemilihan anak yang telah dijalankan pada 11/6/2018 adalah muktamad bagi penentuan hadinah
 - b) Mahkamah menetapkan perbicaraan kes hanya berkaitan tentang lawatan, bersama dan bermalam sahaja.

[14] Kami mendapati YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam membuat keputusan bahawa prosiding pemilihan anak yang telah dijalankan pada 11/6/2018 adalah muktamad bagi penentuan hadinah. YA Hakim Bicara sewajarnya memerintahkan kes tersebut dibicarakan secara menyeluruh terhadap semua isu yang dibangkitkan oleh pihak-pihak dan melihat kepada faktor-faktor lain yang berkaitan demi keadilan pihak-pihak dan kemaslahatan serta kebajikan anak-anak secara keseluruhannya bukan semata-mata berdasarkan kepada sesi temuduga dan pemilihan anak-anak tersebut sebelum membuat keputusan. Proses perbicaraan dalam semua isu wajar dibenarkan dan perbicaraan tersebut bukan hanya tertumpu kepada dua isu sahaja iaitu isu hak lawatan dan hak bermalam sahaja.

[15] Merujuk kepada seksyen 87 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukan bahawa:-

Seksyen 87. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan

(1) Walau apa pun peruntukan seksyen 83, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dengan perintah memilih untuk meletakkan seseorang kanak-kanak dalam jagaan salah seorang daripada orang-orang yang tersebut di dalam seksyen itu atau, jika ada hal keadaan yang luar biasa yang menyebabkan tidak diingini bagi kanak-kanak itu diamanahkan kepada salah seorang daripada orang-orang itu, Mahkamah boleh dengan perintah meletakkan kanak-kanak itu dalam jagaan mana-mana orang lain atau mana-mana persatuan yang tujuan-tujuannya adalah termasuk kebajikan kanak-kanak.

*(2) Untuk memutuskan dalam jagaan siapakah seseorang kanak-kanak patut diletakkan, pertimbangan yang utama ialah **kebajikan kanak-kanak itu** dan, tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada-*

(a) kemahuan-kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu; dan

(b) kemahuan-kemahuan kanak-kanak itu, jika dia telah meningkat umur dapat menyatakan sesuatu pendapatnya sendiri.

[16] Dalam memutuskan kes ini juga, kami telah dipandu oleh kes Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam *Kes Muhammad Riduan bin Baba lwn. Hazlinda biinti Abdul Hamid (Kes Mal (Semakan) No : 10000-003-0015-2011)* sebagaimana berikut :

“ Seterusnya, dijelaskan lagi di dalam seksyen tersebut bahawa pertimbangan untuk memastikan kebajikan anak terpelihara hendaklah mengambilkira kemahuan-kemahuan ibu bapa anak dan juga kemahuan anak yang perlukan jagaan. Ini bermakna, menjadi keperluan seksyen 87(2) itu bahawa hakim bicara hendaklah mengambil keterangan ibu bapa atau pihak yang memohon jagaan dan juga keterangan anak. Keterangan ibu bapa dan anak sangat penting untuk membolehkan hakim dibentangkan fakta sebanyak

mungkin berkaitan hal keadaan yang boleh memenuhi keperluan-keperluan fizikal anak, keadaan persekitaran yang boleh memberi kesan emosi, mental, pemikiran dan agama anak. Perkataan “dan” yang menjadi penghubung sek. 87(2)(a) dan 87(2)(b) menunjukkan tiada pilihan untuk hanya mengambil kira kemahuan salah seorang sahaja. Oleh yang demikian, kegagalan seseorang hakim bicara mengambil keterangan ibubapa dan anak, telah menjejaskan keperluan undang-undang di dalam seksyen 87(2) tersebut melainkan wujud alasan yang munasabah bahawa keterangan ibu bapa dan anak secara zahir adalah tidak wajar diambil, atau terdapat persetujuan oleh kedua-dua pihak yang bertikai atau keadaan anak tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan di dalam sek. 86(2)(b) itu. “

[17] Berdasarkan prinsip yang ditegaskan dalam kes tersebut, yang kami gunapakai dalam kes ini, kami berpuashati bahawa Y.A. Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mengambil keterangan Pemohon dan Respondan bagi membolehkan Y.A. Hakim Bicara mendapat maklumat sebelum membuat perintah yang muktamad berkenaan hak jagaan anak.

[18] Oleh yang demikian, pada hemat kami, adalah perlu untuk kami campurtangan di dalam arahan/perintah tersebut bagi memastikan keadilan diberikan kepada kedua-dua pihak.

KEPUTUSAN

Setelah membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon dan setelah kami memeriksa rekod kes no. 10300-026-0274-2017, maka kami memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Semakan diterima.
2. Y.A. Hakim diarahkah meneruskan perbicaraan Kes Mal No. 10300-026-0274-2017 sehingga selesai dan rekod keterangan anak-anak tersebut boleh digunakan untuk membantu membuat keputusan.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



.....

1. YAA TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

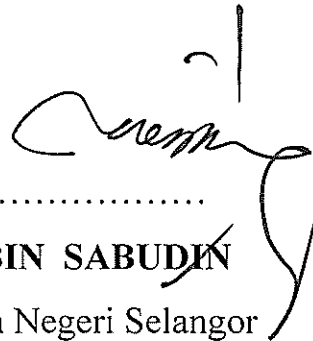


.....

2. YA PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NAI'M BIN MOKHTAR

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

